

NOOR ZAILIZA BINTI ZAINAL ABIDIN

lwn.

MOHD FAIFAL BIN MOHD SIDEK

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

31 Januari 2020 / 6 Jamadilakhir 1441H

Kes Rayuan (Mal) No. : 10000-075-0148-2018

[Rayuan Terhadap Perintah Pengkomitan - Seksyen 151 (1) (b) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Puan Maryam Jameelah Binti Sidek Khalid daripada Tetuan Maryam Sumaiyah & Associates

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Rayuan ini adalah terhadap keseluruhan keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah pada 28 November 2018 dalam kes saman no. 10400-075-0119-2018. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah mengeluarkan perintah seperti berikut;

- 1.1 Mahkamah meluluskan permohonan pengkomitan Pemohon berdasarkan Seksyen 151 (1) (a) (aa) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;*
- 1.2 Mahkamah mensabitkan Responden melanggar Perenggan 4, Penghakiman bertarikh 05.09.2017 melalui kes saman no. 10200-026-0393-2017.*
- 1.3 Mahkamah memerintahkan Responden dikomitkan ke penjara selama tiga (3) hari mulai hari ini.*

2) Perayu tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 28 November 2018 dan mengemukakan lima (5) alasan rayuan bertarikh 29 Mac 2019 seperti di muka surat 243-246 Rekod Rayuan.

FAKTA KES

3) Perayu dan Responden telah bercerai pada 17 Oktober 2016 dan mempunyai seorang cahayamata perempuan bernama Siti Nur Farhah Binti Mohd Faifal yang berusia 3 tahun 1 bulan.

5) Selepas bercerai, Perayu telah memfailkan tuntutan hak penjagaan anak di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui saman no.

10400-028-0700-2016 dan atas persetujuan bersama pihak-pihak, Mahkamah telah mengeluarkan perintah pada 17 Januari 2017.

6) Seterusnya Perayu telah memfailkan tuntutan mengubah perintah hadhanah melalui saman no. 10200-026-0393-2017 dan di atas persetujuan bersama pihak-pihak juga Mahkamah telah merekodkan perintah persetujuan pada 5 September 2017 iaitu antara lain memerintahkan:

“ ...

3. *Mahkamah memerintahkan hak lawatan bersama anak tersebut diberikan kepada Defendan (bapa) pada bila-bila masa yang munasabah dengan memaklumkan kepada Plaintiff (ibu).*
4. *Mahkamah memerintahkan **hak melawat dan tanpa bermalam** bersama anak tersebut pada hujung minggu diberikan kepada Defendan iaitu dua (2) kali dalam sebulan iaitu pada hari Sabtu atau Ahad dari waktu pagi sehingga dikembalikan pada waktu petang dengan makluman terlebih dahulu sehari sebelum perjumpaan kepada Plaintiff dan/atau wakilnya.*
5. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan Defendan hendaklah bersikap bertolak ansur dan saling bekerjasama berkenaan hak bersama anak tersebut dengan meletakkan*

kebajikan (kemaslahatan) anak tersebut sebagai yang paling afdhal dan terutama. “

7) Responden seterusnya memfailkan permohonan interlokutori (Kebenaran Pelaksanaan Pengkomitan) terhadap Perayu pada 15 Februari 2018 melalui Permohonan No. 10400-075-0119-2018. Seterusnya Mahkamah telah mengeluarkan Perintah Kebenaran Mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab pada 13 Mac 2018 manakala Notis Tunjuk Sebab terhadap Perayu telah dikeluarkan pada 26 Mac 2018.

8) Pada 27 Jun 2018, Responden telah menyerahkan Perintah Kebenaran Mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab, Notis Tunjuk Sebab dan Notis Permohonan Kebenaran Mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab beserta Affidavit kepada Perayu semasa prosiding berjalan. Mahkamah telah menangguhkan kes untuk Perayu membela diri dengan memfailkan Affidavit Jawapan dan melantik Peguam (jika ada) untuk mewakili Perayu dalam prosiding pengkomitan, namun Perayu tidak melantik mana-mana Peguam Syarie.

9) Pada 18 September 2018, Perayu telah memfailkan affidavit jawapan manakala Responden telah memfailkan affidavit balasan pada 19 Oktober 2018. Kedua-dua pihak telah memfailkan hujah masing-masing pada 30 Oktober 2018.

10) Keputusan kes telah dibacakan oleh Pendaftar pada 28 November 2018 sepertimana yang diarahkan oleh YA Hakim Bicara.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

11) Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami akan rangkumkan kesemua alasan rayuan Perayu kepada satu isu sahaja iaitu sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan Perayu dikomitkan ke penjara selama tiga(3) hari setelah disabitkan melanggar Perenggan 4, Perintah Persetujuan Bersama berkaitan Ubah Perintah Hak Jagaan Anak.

12) Berdasarkan penelitian kami terhadap keseluruhan kandungan rekod rayuan, kami membuat dapatan seperti berikut;

12.1 Mahkamah telah mengeluarkan Perintah Kebenaran Mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab pada 13 Mac 2018.

12.2 Notis Tunjuk Sebab terhadap Perayu telah dikeluarkan oleh Mahkamah pada 26 Mac 2018 untuk menunjuk sebab

mengapa Perayu tidak patut dikomitkan ke penjara kerana mengingkari perintah Mahkamah bertarikh 5 September 2017 iaitu kerana telah dengan sengaja, cuai melanggar dan memungkiri Perintah berkaitan Ubah Perintah Hak Jagaan Anak melalui Saman No. 10200-026-0393-2017.

12.3 Notis Tunjuk Sebab tersebut beserta Notis Permohonan dan Affidavit serta Perintah Kebenaran Mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab telah diserahkan oleh Responden kepada Perayu semasa prosiding kes berjalan pada 27 Jun 2018. Mahkamah telah mengarahkan Pemohon memfailkan affidavit jawapan dan menetapkan 13 Ogos 2018 untuk pendengaran. Responden telah memfailkan affidavit jawapan pada 19 September 2018 manakala Responden telah memfailkan affidavit balasan pada 19 Oktober 2018. Pihak-pihak telah memfailkan hujah secara serentak pada 31 Oktober 2018.

12.4 Bagi pelaksanaan hak melawat tanpa bermalam tersebut Responden telah menghantar beberapa mesej ringkas (SMS) kepada Perayu untuk memaklumkan tarikh-tarikh Responden ingin membawa anak tersebut keluar tanpa bermalam dan dalam masa yang sama telah mendapat maklumbalas daripada Perayu.

a) Responden telah menghantar SMS kepada Pemohon pada 2 Oktober 2017 memberitahu bahawa pada 15 Oktober 2017 Responden ingin membawa anak tersebut keluar tanpa bermalam. Namun hak tersebut gagal dilaksanakan kerana keluarga Perayu terpaksa pulang ke kampung disebabkan opahnya sakit.

b) Pada 14 Oktober 2017 satu pesanan ringkas telah dihantar untuk memberitahu bahawa pada 22 Oktober 2017 dan 28 Oktober 2017, Responden ingin membawa anak tersebut keluar tanpa bermalam namun ia gagal dilaksanakan kerana anak tersebut dibawa keluar *outstation* oleh bapa Perayu berdasarkan pesanan ringkas Perayu bertarikh 19 Oktober 2017.

c) Pada 9 November 2017, Responden telah menghantar pesanan ringkas kepada Perayu untuk memberitahu bahawa Responden ingin membawa anak tersebut keluar tanpa bermalam pada 25 November 2017 dan 26 November 2017, namun ia gagal dilaksanakan kerana Perayu mempunyai perkara mustahak yang perlu diselesaikan di kampung berdasarkan pesanan ringkas bertarikh 23 November 2017.

d) Pada 26 Disember 2017, Responden telah menghantar pesanan ringkas ingin membawa anak tersebut keluar tanpa bermalam pada 30 Disember 2017 dan 31 Disember 2017, namun gagal dilaksanakan kerana anak tersebut telah mengikut Perayu ke Port Dickson berdasarkan pesanan ringkas Perayu bertarikh 26 Disember 2017.

e) Pada 12 Januari 2018, Perayu telah menghantar pesanan ringkas memaklumkan hendak membawa anak tersebut keluar tanpa bermalam pada 14 Januari 2018, namun gagal dilaksanakan kerana Responden perlu pulang ke kampung untuk melawat opahnya di hospital berdasarkan pesanan ringkas dari Pemohon pada 12 Januari 2018.

12.5 Bagi tempoh bulan Oktober 2017 hingga Januari 2018, Responden tetap dibenarkan oleh Perayu menziarahi anak tersebut walaupun tarikh-tarikh yang dicadangkan oleh Responden tidak dapat dilaksanakan. Responden telah menziarahi anak tersebut pada tarikh-tarikh seperti berikut:

- a) 3 Oktober 2017 (Selasa)
- b) 20 Oktober 2017 (Jumaat)
- c) 16 November 2017 (Khamis)

- d) 22 November 2017 (Rabu)
- e) 30 November 2017 (Khamis)
- f) 27 Disember 2017 (Rabu); dan
- g) 23 Januari 2018 (Selasa)

Pada tarikh-tarikh yang dicadangkan oleh Responden anak tersebut terpaksa dibawa bersama oleh Perayu kerana memerlukan perhatian dan penjagaan yang rapi. Anak tersebut telah menunjukkan simptom-simptom autisme seperti tidak mahu *baby talk (babbling)*, lambat bercakap, tidak mahu memberi reaksi, tiada *eye contact* dan tidak fleksibel dan bersifat hiperaktif.

13) Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut kami berpendapat YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana tidak membuat pertimbangan yang konklusif terhadap pembelaan yang telah dibuat oleh Perayu. Kes ini melibatkan tindakan pengkomitan dan berkait dengan kebajikan seorang anak kecil yang berumur tiga (3) tahun satu (1) bulan. Seharusnya dalam kes seumpama ini YA Hakim Bicara perlu bertindak dengan menggunakan pertimbangan yang sesuai atau mizan secara lebih berhati-hati dan waspada sebagaimana pandangan Hakim dalam kes **Helen Yeap Poh Sin lwn. Universal Trustee (Malaysia) Bhd., (2001) 7 CLJ 414** yang menyatakan kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan seseorang ke penjara kerana kegagalan mematuhi perintah Mahkamah perlu

dijalankan dengan berhati-hati. Begitu juga dengan pandangan Hakim Bicara di dalam kes **Haji Azman Bin Abdul Talib lawan Suhaila Binti Ibrahim [2001] CLJ (Sya) 392**, Hakim Abdul Rahman Yunus telah memakai prinsip Mahkamah Sivil sewaktu membebaskan Responden dari perintah komital kerana kegagalan mematuhi perintah Mahkamah dengan menyatakan “*kuasa Mahkamah untuk mengkomitkan seseorang ke penjara kerana kegagalan mematuhi perintah Mahkamah perlu dilaksanakan dengan penuh berhati-hati*”.

12) Begitu juga dalam kes **Re Bramblevale Ltd [1970] 1 CH 128** (**Lord Denning MR** telah menyatakan:

A contemp of court is an offence of a criminal character. A man may be sent to prison for it. It must be satisfactorily proved. To use the time honourable phrase it must be proved beyond reasonable doubt.

Prinsip ini telah digunakan di Mahkamah Sivil dan menepati kaedah perundangan Islam yang digunapakai di Mahkamah Syariah.

13) Dalam kes yang melibatkan hak jagaan terhadap anak yang masih kecil, Kami berpendapat Mahkamah juga seharusnya mengambil perhatian bahawa soal kebajikan anak-anak adalah lebih utama berbanding dengan soal hak ibu dan bapa ke atas kanak-kanak yang dipertikaikan. Hak anak (mahdhun) hendaklah diutamakan berbanding

hak pihak-pihak yang memelihara sebagaimana difahamkan daripada fatwa Ibnu Al-Salah di dalam ‘*Tuhfah*’ dan ‘*Nihayah*’ serta diakui muktamadnya oleh Ali Shabramulsi sebagaimana yang disalin oleh Syed Syabiq dalam *Fiqh al-Sunnah Juz. 8* yang bermaksud;

“Sesungguhnya setiap yang menjaga dan yang dijaga (anak) mempunyai hak dalam pemeliharaan tetapi hak yang dijaga lebih kuat daripada hak yang menjaga dan diterangkan oleh Ibnu Qudamah yang bermaksud; Thabitnya hadhanah adalah untuk menentukan nasib (kepentingan) budak (kanak-kanak) itu “.

14) Dalam rayuan ini kami dapati alasan-alasan yang diberikan oleh Perayu sememangnya ada dalam pengetahuan Responden atau dengan erti kata lain Responden sedia maklum dan mengetahui dengan mendalam sebagaimana mesej pihak-pihak di muka surat 19-51 Rekod Rayuan. Alasan-alasan yang diberikan oleh Perayu pula bukanlah alasan-alasan yang disengajakan dan seharusnya mendapat pertimbangan yang sewajarnya daripada Mahkamah. Antara mesej yang menarik perhatian kami ialah di muka surat 23 dan 24 Rekod Rayuan.

“ Assalamualaikum, maaf... minggu ni awk xdpt jumpa farhah. Sy dan keluarga pulang ke kg, sbb opah sy sakit...”

“Bila blk kg? Hari ni? Saya doakan kesejahteraan opah awak...Aminnn....”

Walaupun hak melawat tanpa bermalam tidak dapat dilaksanakan pada tarikh-tarikh yang dicadangkan oleh Responden namun kami dapati Responden ada bertindak dengan datang melawat anak tersebut sebaik sahaja mendapat maklumbalas daripada Perayu. Perayu pula dalam masa yang sama telah membenarkan tanpa halangan hak lawatan Responden seperti berikut;

- i) Responden apabila dimaklumi oleh Perayu tidak dapat berjumpa dengan anak tersebut pada tarikh cadangan 22.10.2017 dan 28.10.2017 telah bertindak menziarahi anak tersebut pada 20.10.2017.
- ii) Responden apabila dimaklumi oleh Perayu tidak dapat berjumpa dengan anak tersebut pada tarikh cadangan 25.11.2017 dan 26.11.2017 telah bertindak menziarahi anak tersebut pada 16.11.2017, 22.11.2017 dan 30.11.2017.
- iii) Responden apabila dimaklumi oleh Perayu tidak dapat berjumpa dengan anak tersebut pada tarikh cadangan 30.12.2017 dan 31.12.2017 telah bertindak menziarahi anak tersebut pada 27.12.2017.

iv) Responden apabila dimaklumi oleh Perayu tidak dapat berjumpa dengan anak tersebut pada tarikh cadangan 14.1.2018 telah bertindak menziarahi anak tersebut pada 23.01.2018.

15) Pada hemat kami walaupun hak Responden untuk melawat pada hari Sabtu atau Ahad sepertimana tarikh-tarikh yang telah dicadangkan tidak dapat dilaksanakan namun ianya bukanlah bererti hak Responden untuk melawat tersebut dinafikan terus oleh Perayu. Terbukti dalam rayuan ini Responden telah datang melawat dan menziarahi anak tersebut pada 3 Oktober 2017 (Selasa), 20 Oktober 2017 (Jumaat), 16 November 2017 (Khamis), 22 November 2017 (Rabu), 30 November 2017 (Khamis), 27 Disember 2017 (Rabu) dan 23 Januari 2018 (Selasa), cuma pada tarikh-tarikh yang dicadangkan tersebut terdapat sebab-sebab tertentu yang menyebabkan Responden tidak dapat keluar bersama dengan anak tersebut. Ini menunjukkan kepada kami bahawa kegagalan mematuhi perintah Mahkamah tersebut bukanlah suatu yang secara total disengajakan oleh Perayu dan ianya masih lagi tidak mencapai suatu tahap yang mewajarkan hukuman penjara dikenakan. Pada hemat kami juga, di peringkat inilah Mahkamah seharusnya menggunakan mizan atau budibicaranya untuk menyelesaikan pertikaian pihak-pihak sebelum menggunakan peruntukan berkaitan dengan hukuman penjara.

16) Kami juga telah meneliti peruntukan Seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) yang menyebut;

“... ”

tertakluk kepada Enakmen ini, penghakiman atau perintah itu bolehlah dikuatkuasakan melalui satu atau lebih daripada satu cara yang berikut, iaitu—

... ”

Kami berpendapat penggunaan perkataan ‘bolehlah’ dalam peruntukan tersebut menunjukkan bahawa Mahkamah masih mempunyai ruang budi bicara sebelum mempertimbangkan hukuman pengkomitan.

16) Dalam menimbangkan rayuan ini kami juga dipandu oleh keputusan Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Zetty Binti Zabir Iwn. Mohammed Rafi Bin Mohamed Yaacob, JH 36 BHG. I, 1434H, halaman 161-179**. Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes tersebut telah memberi panduan dalam mempertimbangkan tunjuk sebab bagi tindakan pengkomitan.

“ Berdasarkan Alasan Penghakiman tersebut, jelas bahawa YA Hakim Bicara menolak sepenuhnya tunjuk sebab tersebut tanpa menilai sama ada tunjuk sebab tersebut wajar dan munasabah. Ini menjadikan prosiding pengkomitan itu sebagai suatu prosiding hanya untuk menentukan sama ada berlaku pelanggaran/keenggaran mematuhi perintah Mahkamah. Kami ingin memberikan panduan di sini bahawa

di dalam prosiding pengkomitan, Mahkamah bukan sahaja perlu memutuskan sama ada berlaku keengkaran, tetapi juga perlu memutuskan sama ada patut Penghutang Penghakiman dikomitkan setelah mempertimbangkan sebab-sebab yang membawa keengkaran mematuhi perintah.”

17) Dalam rayuan ini kami dapati kegagalan Perayu melaksanakan perintah yang telah dipersetujui bukanlah suatu yang disengajakan tetapi mempunyai sebab-sebab yang tertentu yang pada hakikatnya memang diketahui oleh Responden. Walaupun Responden tidak dapat berjumpa dengan anak tersebut pada hari Sabtu atau Ahad seperti yang dicadangkan, namun ianya tidaklah menafikan sepenuhnya hak Responden untuk melawat dan bersama dengan anak tersebut. Dalam situasi seperti ini kami berpendapat tindakan memberi peringatan atau amaran kepada Responden di samping perintah menggantikan hari-hari yang Responden tidak dapat bersama dengan anak tersebut adalah lebih bersesuaian sebagai tindakan pembetulan dan pencegahan, berbanding mengenakan hukuman penjara yang boleh mendatangkan kesan yang lebih mudharat ke atas Perayu selaku hadhinah dan menafikan kerahmatan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah kedua-dua pihak, maka kami sebulat suara memutuskan sebagaimana berikut:

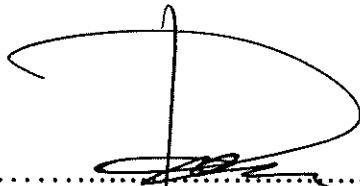
1. Rayuan Perayu diterima.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes saman no. 10400-075-0119-2018 bertarikh 28 November 2018 adalah dipinda keseluruhan kepada;
 - 2.1 Mahkamah memberi peringatan kepada Perayu agar mematuhi dan memberi keutamaan kepada pelaksanaan perintah Mahkamah yang telah dipersetujui bersama oleh pihak-pihak. Kegagalan atau kecuaian Perayu secara sengaja mematuhi Perintah Mahkamah akan dikenakan tindakan pengkomitan.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



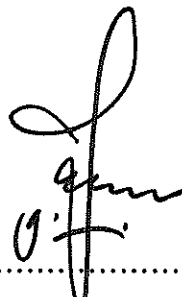
.....
1. YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIFF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
3. YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor